

1513370-80.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513370-80.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513370-80.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328499/2021 - 02º D.P. AMERICANA, 21739527 - 02º D.P. AMERICANA, 1934/21/345 - 02º D.P. AMERICANA, 2328499 - 02º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO COELHO BORTOLETO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

CARLOS ALBERTO COELHO BORTOLETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº. 10.826/2003, na forma de concurso material, porque, na data e local descritos na denúncia, em via pública, foi surpreendido portando arma de fogo (uma espingarda da marca E. R. AMANTINO & CIA LTDA., BOITO, calibre 12 GA, com número de série BF34567), de uso permitido, mas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, uma pistola semiautomática da marca FN (Fabrique Nationale D'Herstal), calibre nominal 25 AUTO (6,35mm Browinig), com número de série 878248, além de seis cartuchos íntegros, do mesmo calibre, em

condição de uso, e também inúmeras munições, tudo, de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

E, ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 14, da Lei nº. 10.826/2003, porque, na data e local descritos na denúncia, foi surpreendido portando arma de fogo (um revólver da marca AMADEO ROSSI, calibre nominal 22 LR, com número de série 398414, número de montagem 7350), de uso permitido, mas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fls. 216/217).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 234 e 262), apresentando defesas (fls. 244/245 e 257/258).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas. Os réus deixaram de comparecer ao interrogatório, tornando-se revéis (fls. 325/326).

Em seus memoriais (fls. 330/336), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente com a conseqüente condenação dos réus.

Ao manifestar-se (fls. 339/342), a Doutora Defensora do réu Carlos requereu sua absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente a aplicação de atuantes e fixação de pena mínima com regime mais brando.

E, a Doutora Defensora do réu Anderson (fls. 343/345) alegou preliminar de atipicidade de conduta, e no mérito, requereu sua absolvição por falta de provas.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A alegada preliminar de atipicidade da conduta se confunde com o mérito, e com ele será analisada.

No mérito, a ação penal é procedente.

O auto de fls. 01, 07/10, e 11/13 demonstram a materialidade do delito e os laudos de fls. 172/181 comprovou a eficácia das armas. Os laudos referentes as munições e demais objetos também foram apresentados (fls. 182/184, 185/202, 265/268 e 269/271).

A autoria é indubitosa.

Os réus foram presos em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-

se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Os réus nem sequer se dignaram em comparecer em Juízo para dar suas versões dos fatos.

Na Delegacia Carlos alegou possuir registro da arma (fls. 06) e Anderson negou a prática do delito (fls. 05). Todavia, suas versões não encontram respaldo no conjunto probatório.

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, a Policial Militar Claudia declarou receberam uma denúncia acerca de um indivíduo, com o veículo próximo da escola, em posse de uma arma. Dirigiram-se ao local, e abordaram o réu Carlos, na porta da escola, o qual aparentava a ingestão de bebidas alcoólica. Em revista ao veículo, encontraram uma arma calibre 12. Em diligência a residência do réu, encontraram a companheira e outro indivíduo, Anderson, com uma bicicleta e uma mochila nas costas. Em vistoria na mochila, localizaram mais armas de fogo. No interior da casa, encontraram diversas munições e mais uma arma de fogo.

E a Guarda Municipal Vanessa disse que estavam em patrulhamento quando foram informados por populares que um indivíduo, com uma arma calibre 12 estava ameaçando os pedestres. Dirigiram-se ao local, e não localizaram o indivíduo, mas verificaram a arma no interior de um veículo. Narrou, ainda, que foi informada que a abordagem do réu Carlos foi efetuada pela polícia militar, em frente a escola. Por fim, o réu foi conduzido até o veículo, onde foi apreendida a arma.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas (“Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os

crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).(...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

Em que pese a alegação da defesa de Anderson, não há que se falar em atipicidade de conduta, por não saber que as armas estavam em sua mochila, tendo em vista que sua alegação restou improzada. E, como é sabido, o ônus de provar incumbe a quem faz a alegação.

Ônus da prova é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal.

Segundo o artigo 156 do Código de Processo Penal “ a prova da alegação incumbirá a quem a fizer ...”.

No processo penal condenatório, cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes, etc.), o elemento subjetivo: dolo e culpa (deve provar a inobservância da cautela devida: imprudência, negligência ou imperícia).

Ao acusado cabe a prova das causas excludentes de antijuridicidade (legítima defesa, etc.), da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que

impliquem em diminuição da pena (atenuantes, causas de privilégio, etc.), ou de benefícios, ou ainda de elementos subjetivos que o possam beneficiar (violenta emoção, etc.). Cabe, ainda, ao réu a prova da “inexistência do fato” se pretender a absolvição com base no artigo 386, I do CPP.

No entanto, a alegação de Anderson que teria apenas buscado a mochila na casa de Carlos, não tendo conhecimento de que as armas foram lá armazenadas, não ficou comprovada nos autos, tendo em vista, inclusive, as declarações de fls. 04. Ora, o réu apresenta álibi, sem, no entanto, comprová-lo. A alegação não comprovada de álibi é também indício que milita em desfavor do réu.

No mais, é importante indício o fato do réu Carlos já ter sido processado por outro delito envolvendo porte de arma (Proc. 0000163-40.2017.8.26.0630), e Anderson possui diversos antecedentes em delito contra o patrimônio (fls. 91/114), o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, é indício que fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

A respeito da prova indiciária, nesse sentido é o entendimento da doutrina: “A prova da autoria não se faz apenas por confissão espontânea ou por declaração das testemunhas, mas, muitas vezes, com base em prova meramente indiciária. Constitui erro crasso, como diz Mestre Frederico Marques, citando Vito Gianturco, o afirmar-se de que nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará lugar à condenação, pois tal assertiva equivaleria a abolir-se a prova indiciária do processo penal (MARTINS, Weber “O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal” - Forense - Rio de Janeiro - 1995 - p. 459).

Como já entendido por nossos Tribunais:

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL - CONDENAÇÃO VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Existindo provas indiciária e circunstancial concludentes, no que tange a existência da consciência da origem espúria do bem pelo agente, circunstâncias essas aliadas à palavra dos policiais que não teriam motivo algum para uma falsa inculpação, impossível de se cogitar a absolvição. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000710-

58.2011.8.26.0091; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 09/09/2014)

"O indício vale como qualquer outra prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao juiz sopesar a valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do artigo 239 do Código de Processo Penal" (Ap.1070845/5, Rel. Renato Nalini, j. 06.10.1997, rolo 1132, flash 0194, fls.09).

PROVA - Presença de indícios concatenados - Ausência de prova direta que os desautorize - Validade - Entendimento:61 - Sendo a prova indireta mas segura, formada por indícios concatenados, sem contra-indícios ou prova direta que os desautorize, possível é a condenação nela baseada, mormente se a materialidade do delito é inconteste. RJDTACRIM VOLUME 16 OUTUBRO/DEZEMBRO/1992 PÁGINA: 133
RELATOR: - MARREY NETO

PROVA - Furto - Presença de indícios - Valor:182 - Sendo os crimes de furto praticados normalmente sem a presença de testemunhas, os indícios passam a ter valor relevante para a apuração da autoria. RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 324 RELATOR: - MESQUITA DE PAULA

Desta forma, a prova produzida comprova a posse/guarda e porte das armas de fogo de uso permitido, mas sem autorização para tanto.

Diante do conjunto probatório, a condenação dos acusados é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Relativo a Carlos. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em um ano de detenção e dez dias-multa, para a posse. E, em dois anos de reclusão e dez dias-multa, para o porte.

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente específico, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 76/79. Acrescento à pena base, portanto, 1/6 (um sexto) pela reincidência, perfazendo um total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, para a posse. E, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para o porte.

Ante a ocorrência de concurso material (art. 69, do CP), em relação aos crimes de posse e porte de armas, as penas devem ser somadas.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de

Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Relativo a Anderson. O réu na época dos fatos era tecnicamente primário. No entanto, as certidões de fls. 91/114, comprovam a existência de diversos processos já sentenciados, o que impõe a majoração da pena base como circunstância judicial. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto) fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o delito de porte.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

Tendo em vista a conduta social e a personalidade do réu (art. 44, inc. III, do CP), deixo de conceder-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por faltar-lhe o requisito da suficiência, ex vi legis.

Por fim, os réus poderão apelar em liberdade, por estarem respondendo soltos ao presente processo, e por estarem ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu CARLOS ALBERTO COELHO BORTOLETO, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso, como incurso nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº. 10.826/2003. E, condenar o réu ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 14, da Lei nº. 10.826/2003.

Por fim, considerando estarem os réus assistidos pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-os das custas.
P. I. C.

Americana, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA